



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0003754-92.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARCELO GERMANDO DE ANDRADE**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Erica Regina Colmenero Coimbra**

Vistos

MARCELO GERMANDO DE ANDRADE, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, *caput*, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 244-B da lei nº8.069/90, c/c artigo 69 do Código Penal, sob acusação de, no dia 20 de abril de 2017, pro volta das 12h, na Favela do Vietnã, Rua Coriolano Durand, Jabaquara, nesta Capital e Comarca, trazia consigo e adquiriu sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar e visando o comércio ilegal de, 25,3 gramas de cocaína destruídos em 120 porções, 8,8 gramas de crack distribuídos em 41 pedras, 24,2 gramas de “Cannabis Sativa L” distribuídos em 26 porções e 12,2 de ecstasy sob a forma de 40 comprimidos, conforme laudo (fls 35/37).

Consta ainda que por volta das 12h no mesmo local supracitado, o indiciado e o menor de 15 anos *Carlos Xavier Ferreira da Silva*, previamente ajustados e com identidade de propósitos, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 *caput* da Lei nº11.343/06.

A denúncia foi devidamente recebida (fls. 146/147), sendo determinada a citação do acusado para apresentação de Defesa Preliminar, bem como designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de agosto de 2017. O acusado apresentou defesa fls. 185/186.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o acusado foi



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

interrogado. Na sequência, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, manifestou-se contrariamente, pleiteando a improcedência da ação penal por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. No mais, indica a inexistência dos crimes de associação para o tráfico, bem como a corrupção de menores. Em teses subsidiárias, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal; pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006; pela fixação de regime inicial menos gravoso; pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como seja facultado ao acusado o apelo em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser **julgada improcedente**. A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/04), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14/18), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19/20), pelo Laudo químico toxicológico (fls. 161/163), bem como prova oral produzida nos autos.

A autoria, porém, não recai sobre o acusado. Vejamos.

A testemunha policial civil **ALEX CARLOS DE SANTANA**, ouvido em juízo, reconheceu o réu. Afirma que na semana anterior a abordagem, foi realizada uma diligência no local, conhecido ponto de venda de entorpecentes. Nesta oportunidade, ao avistar a polícia o réu correu para dentro da comunidade e gritou "polícia." Os traficantes correram e abandonaram a droga no local. Na data dos fatos, o depoente realizou nova diligência e se fez passar por morador da região. Nessa oportunidade conseguiu prender o réu. Os demais policiais conseguiram apreender um adolescente que portava entorpecentes. O réu atuava como olheiro. Ele avisava os outros sobre a chegada da polícia. O réu, quando detido, confirmou que atuava como "olheiro" do tráfico. Anteriormente a essas diligências não realizou outras abordagens ao réu. Às perguntas da acusação reiterou que o adolescente foi apreendido com as drogas.

A testemunha policial civil **SAMUEL DE FREITAS**, ouvido em juízo, reconheceu o réu. Relata que as investigações no local, já vinham sendo feitas há uma semana. Em uma primeira diligência realizada na Favela do Vietnã, conhecido ponto de venda de entorpecentes, relata que o réu estava sentando em uma cadeira e quando avistou a polícia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

chegando, saiu correndo para avisar os traficantes. Eles conseguiram fugir, mas abandonaram a droga no local. Na data dos fatos foi realizada nova diligência sendo que o policial Alex se fez passar por morador da região e foi na frente. O réu atuava como olheiro ou campana, da mesma maneira que atuava na semana anterior. Ele avisava os outros sobre a chegada da polícia. O réu foi abordado, pois não percebeu que Alex era policial. Um adolescente também foi apreendido no fundo da viela, na posse de vários entorpecentes. Anteriormente a essas diligências não realizou outras abordagens ao réu. Às perguntas da acusação confirmou que o réu atuava como olheiro. Às perguntas da defesa respondeu que as drogas foram encontradas com o adolescente apreendido e não com o réu.

A testemunha policial civil **EDUARDO X. DOS SANTOS**, ouvido em juízo, reconheceu o réu. Afirma que dias antes dos fatos, sua equipe realizou uma diligência no local, conhecido ponto de venda de entorpecentes. O réu estava sentado em uma cadeira e, ao avistar os policiais, correu e avisou aos demais. Todos conseguiram fugir, mas a droga foi abandonada no local e posteriormente apreendida. Na data dos fatos, nova diligência foi realizada e Alex se fez passar por morador da região e dessa vez conseguiu prender o acusado. Um adolescente foi apreendido no fundo da viela na posse de vários entorpecentes: maconha, cocaína e haxixe, sendo que outro indivíduo conseguiu fugir. No dia dos fatos o réu não apresentou qualquer versão. O réu atuava como olheiro ou campana. Ele avisava os outros sobre a chegada da polícia. Anteriormente a essas diligências não realizou outras abordagens ao réu.

O réu, em seu interrogatório judicial, afirma que trabalha em uma empresa de reciclagem. Estava em seu horário de almoço quando foi detido no interior da comunidade. Os policiais detiveram um adolescente em uma lanchonete e atribuíram o crime falsamente ao interrogando. Nem chegou a ver os policiais. Já possui apontamento criminal, por tráfico de drogas. Já cumpriu sua pena.

Diante do conjunto probatório e dos depoimentos colhidos em Juízo, constata-se que as provas dos autos não se mostram hábeis a demonstrar, inequivocamente, que o acusado cometeu o crime tráfico de drogas, de associação para o tráfico de entorpecentes ou mesmo aquele descrito no art. 244-B do ECA. Senão vejamos.

Primeiramente, necessário salientar que gozam os policiais dos “adjetivos atribuíveis à autêntica testemunha”, presumindo-se a legitimidade dos atos que, enquanto



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

servidores públicos, praticam no exercício de suas funções.

Assim, tratando-se de presunção relativa, à defesa cumpria afastar a veracidade de tais depoimentos, demonstrando alguma dissonância no tocante ao contexto probatório ou o particular interesse dos policiais na solução da causa. A propósito: “*PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE*”. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. *Habeas corpus não conhecido*”. (STJ: HC 206282 SP 2011/0105418-9. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO – T6 Sexta Turma. Dje: 26/05/2015)

Vale ressaltar que os policiais, ouvidos em juízo, afirmam, de forma, uníssona que constataram que o réu atuava como “olheiro”. Relataram que, em uma primeira diligência, presenciaram o acusado sentado em uma cadeira, sendo que logo que avistou os policiais agindo, saiu correndo e gritando para avisar outros indivíduos. Nesta diligência, nenhum indivíduo fora preso, somente houve apreensão de entorpecente.

Na data dos fatos, em nova incursão pelo local, avistaram o réu no mesmo local, porém, conseguiram prendê-lo. Os policiais indicaram ainda que foi apreendido um menor que portava as drogas apreendidas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Importante ressaltar que, como descrito, as drogas apreendidas não foram encontradas na posse do acusado. Em verdade, conforme descreveram as testemunhas, os entorpecentes foram encontrados na posse do menor apreendido (Carlos). Some-se a isso o fato de que nenhuma das testemunhas teria visto, de fato, o réu praticando qualquer ato de mercancia.

Repise-se que todas as testemunhas de acusação descreveram a conduta do réu como a de um verdadeiro “olheiro” e não como traficante.

Nesse sentido, inviável a condenação do acusado, nos termos indicados na denúncia, ao menos no que tange a imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Mais adequada ao fato seria a imputação referente ao crime descrito no art. 37 da Lei 11.343/06 tendo em vista que, restou claramente constatado, que se tratava o réu de mero campana, ou seja, colaborador/informante.

Seguindo esta linha de raciocínio, é de suma importância notar que não também não há provas concretas que sejam hábeis a comprovar o *animus associativo* entre o acusado e o menor apreendido. Ora, ainda que possível a hipótese de associação, com a finalidade de cometer o crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há nos autos provas contundentes necessárias a embasar uma condenação por um delito de tamanha gravidade, sendo que a prudência aqui recomenda a aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Com efeito, são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) *existência de dois ou mais infratores*; b) *existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade*; c) *a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica*; d) *delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei*.

Portanto, se ausente um destes requisitos, resta configurada uma associação momentânea, regulada na lei penal como concurso de pessoas, tratando-se de uma causa especial de aumento da pena e não um delito autônomo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos de sua definição. Neste sentido preleciona Vicente Greco Filho: *"Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..."* (GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei nº 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei nº 6.368/76 - 12ª ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127).

Dessa forma, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um *animus associativo*, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris* em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico. Nesse sentido o seguinte julgado:

"Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recursos defensivos buscando a absolvição por falta de provas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação apenas pelo delito de tráfico de entorpecentes. Não comprovação do animus associativo prévio, com estabilidade e permanência. Mero concurso de agentes. Absolvição pelo crime de associação decretada. Ré Jennifer primária. Confissão que não pode reduzir as penas para alguém do mínimo legal. Súmula nº 213 do C. STJ. Réu Wellington reincidente. Pleito subsidiário de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Não acolhimento. Natureza, quantidade de drogas e circunstâncias do caso concreto indicando que a ré se dedicava a essa atividade criminosa. Quantum da pena que inviabiliza a substituição por sanções restritivas de direitos. Regime inicial fechado mantido. Recursos parcialmente providos. Com determinação. (TJSP: APL 00430331020138260576 SP. Relator: Sérgio Coelho - 9ª Câmara de Direito Criminal. DJe: 01/07/2015).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Conforme relatado pelos policiais que participaram das diligências houve apenas a apreensão de um menor de idade, que portava drogas consigo, sendo certo que não há provas que o réu e o adolescente estavam associados, no máximo um auxílio eventual. Em seu interrogatório o réu nega a prática delitiva e indica que não conhece o menor apreendido.

Portanto, não há elementos concretos capazes de comprovar que o réu estivesse associado com o menor de idade apreendido e ou outros indivíduos.

Destaco o julgado, nesse contexto o seguinte julgado: “*EMENTA: art. 37 e 33 da Lei nº 11.343/06 – Recurso Defensivo PRELIMINARES - Nulidade - Cerceamento de defesa pela inobservância do artigo 400, do Código de Processo Penal INADMISSIBILIDADE A Lei nº 11.343/06 é lei especial e prevalece sobre a norma geral - Constitucionalidade do Artigo 57, da Lei de Drogas. Arguição de inconstitucionalidade da norma penal em branco INADMISSIBILIDADE. Inobservância do artigo 384 do Código de Processo Penal POSSIBILIDADE cerceamento de defesa caracterizado - réu denunciado por infração ao art. 37 e condenado pelo artigo 33, ambos da Lei 11.343/06 sem aditamento da inicial. Reconhecimento da atipicidade da conduta. POSSIBILIDADE Não há prova de colaboração do apelante com grupo, organização ou associação atipicidade da conduta - Absolvição de rigor – decisão mais benéfica ao apelante. Recurso provido.*” (TJSP: 0005713-75.2011.8.26.0161. Relator. PAULO ANTONIO ROSSI - 12ª Câmara de Direito Criminal. 24/12/2012).

Já quanto ao delito de corrupção de menores não há elementos de convicção aptos a demonstrar que o réu induziu de qualquer forma o menor a cometer o crime. Há entendimentos que sustentam que para a configuração do crime previsto é necessário que o agente tenha, de qualquer forma, contribuído para a participação do menor no crime.

Ademais, não restou demonstrada, com clareza sequer a relação entre o acusado e o menor apreendido.

Para que haja o delito de corrupção de menores é necessário que o agente pratique uma das condutas descritas no tipo legal: facilitar ou corromper, não sendo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

suficiente para caracterizá-lo o fato de haver participado do crime criminoso em companhia de menores. (STJ - REsp. nº 127.692 - DF - Rel. Min. Edson Vidigal - J. 16.12.97 - DJU 19.05.98).

Ante o acima descrito, é de rigor absolver o réu do delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por insuficiência de provas.

Diante do exposto, **julgo improcedente** a pretensão punitiva estatal para o fim de **ABSOLVER o réu MARCELO GERMANDO DE ANDRADE**, devidamente qualificado nos autos, da imputação nos artigos 33, *caput*, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 244-B da lei nº8.069/90, **nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.**

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 01 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**